



DOMINANDO

FALTA GRAVE



CLAUDIA GENNARI
CADA DIA DE LIBERDADE IMPORTA

FALTA GRAVE

CLAUDIA GENNARI

1 - INTRODUÇÃO

2 - DEVERES DO PRESO

3 - ESPÉCIES DE SANÇÕES DISCIPLINARES

4 - DOŠIMETRIA DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

5 - FALTA DISCIPLINAR GRAVE

6 - PAD – PROCEDIMENTO ADM

7 - INISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR

- CONTROLE DA LEGALIDADE**

8 - APURAÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE

- AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO**

9 - SANÇÕES JUDICIAIS

- REGRESSÃO DE REGIME**

- PERDA DE DIAS REMIDOS**

- REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO**

- REVOGAÇÃO DE SAÍDE TEMPORÁRIA**

- ALTERAÇÃO DA DATA BASE**

- VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL**

- TRANSFERÊNCIA PARA O RDD – REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO**

10 - DAS ESPÉCIES DE FALTA GRAVE

. INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA

. FUGA

. POSSUIR, INDEVIDAMENTE, INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM

. PROVOCAR ACIDENTE DE TRABALHO

. DESCUMPRIR, NO REGIME ABERTO, AS CONDIÇÕES IMPOSTAS

. INOBSERVAR OS DEVERES PREVISTOS NOS INCISOS II E V, DO ARTIGO 39, DESTA LEI

. TIVER EM SUA POSSE, UTILIZAR OU FORNECER APARELHO TELEFÔNICO, DE RÁDIO OU SIMILAR, QUE PERMITA A COMUNICAÇÃO COM OUTROS PRESOS OU COM O AMBIENTE EXTERNO.

. RECUSAR SUBMETER-SE AO PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO

. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO

11 - SANÇÕES DISCIPLINARES

· DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE

12 - PRESCRIÇÃO

13 - REABILITAÇÃO DA FALTA GRAVE

14 - CONCLUSÃO FINAL

INTRODUÇÃO

O BICHO PAPÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PRA QUALQUER PRESO/SENTENCIADO É, SEM DÚVIDA NENHUMA:

FALTA GRAVE !

MAS, também é para nós, Advogadas e Advogados Criminalistas, especialistas em Execução Penal o MAIOR dos PIORES pesadelos.

Isto porque, a FALTA GRAVE influencia em toda a EXECUÇÃO PENAL do Cliente, retirando-lhe direitos essenciais para a conquista da tão sonhada LIBERDADE.

Por isso se faz de extrema valia que VOCÊ, Advogado e Advogada, conheça tudo sobre a FALTA DISCIPLINAR GRAVE: quais são as condutas que tipificam FALTA GRAVE, como deve ser o Procedimento Administrativo para apuração da falta grave; a importância da participação de uma defesa efetiva e combativa durante o PAD; as sanções administrativas e judiciais que podem ser aplicadas em função do cometimento de uma falta grave; a HOMOLOGAÇÃO da falta grave e suas consequências; a PRESCRIÇÃO administrativa e judicial das Faltas Graves e, por fim, a REABILITAÇÃO de FALTA GRAVE.

MAS não se preocupe, vem comigo que vou te entregar um MANUAL completo sobre o que de mais importante você precisa saber sobre o cometimento de FALTA DISCIPLINAR GRAVE.

Com linguagem simples e objetiva, mesmo que você ainda não tenha muita prática com este assunto, vai ser capaz de acompanhar e garantir a defesa de seu cliente, a partir agora!

CONFIRA!

DEVERES DOS PRESOS

Para se falar em cometimento de FALTA DISCIPLINAR é necessário falar sobre os DEVERES DOS PRESOS, ou seja, as OBRIGAÇÕES que devem ser CUMPRIDAS pela pessoa CONDENADA durante o CUMPRIMENTO DE SUA PENA, especialmente o DEVER DE DISCIPLINA.

Os DEVERES DO PRESO estão previsto no Art. 39 da LEP, tratando-se de um ROL TAXATIVO e aplicável, também, aos PRESOS PROVISÓRIOS.

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vítima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.

Quando a pessoa condenada **INGRESSA NO SISTEMA PRISIONAL** ele é, obrigatoriamente, **INFORMADO** acerca de todas as normas da Unidade prisional onde será recolhido, não podendo, portanto, alegar ignorância ou desconhecimento de tais regras.

Por este motivo que, assim que a pessoa é presa, ela fica separada por um determinado tempo dos demais. Para que possa “conhecer” dos seus **DEVERES**, como deve ser sua conduta dentro daquele estabelecimento prisional.

E é, exatamente do **DESCUMPRIMENTO** de tais regras (deveres do preso), que advém o reconhecimento, homologação e aplicação de sanções, tanto administrativas (pelo diretor da unidade prisional) como judiciais (pelo juízo da execução penal).

Assim, o **DESCUMPRIMENTO** das regras impostas nos leva ao tema deste e-book. Dentre as **FALTAS DISCIPLINARES**, a **FALTA GRAVE** é, sem dúvidas, o maior pesadelo do preso.

Por isso, traremos uma **MANUAL** completo sobre o tema para que você, Advogada e Advogado atuante na Execução Penal esteja preparado!

ESPÉCIES DE SANÇÕES DISCIPLINARES

LEP. Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

Decorrente do princípio da legalidade e da anterioridade, toda FALTA DISCIPLINAR e, as possíveis SANÇÕES DISCIPLINARES, a serem aplicadas ao sentenciado/condenado devem estar PREVISTAS EM LEI.

O Artigo 53 da LEP prevê o ROL TAXATIVO das SANÇÕES que podem ser impostas ao condenado:

Art. 53. Constituem sanções disciplinares:

I - advertência verbal;

II - repreensão;

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado.

Importante observar, que, as sanções de: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento, serão aplicadas pelo diretor do estabelecimento prisional, não dependendo de "autorização", concordância ou homologação judicial. Sempre, obviamente, advindo de um ato administrativo motivado, isto é, por escrito e devidamente justificado.

Já a decisão por incluir um sentenciado no RDD – Regime Disciplinar Diferenciado, cabe APENAS ao Juízo da Execução Penal.

DOSIMETRIA DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Considerando-se, portanto, a existência de ALTERNATIVAS para a APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISCIPLINARES é preciso que exista, também, uma definição de como será a aplicação das possibilidades de sanções, de forma a respeitar-se o princípio da “individualização” da conduta, tal como ocorre na aplicação da própria pena, pelo Juiz da condenação.

Esta previsão esta contida no Art. 57 da LEP:

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Deverá, portanto, ser considerado pelo Diretor da Unidade Prisional, ao “decidir” pela aplicação de uma sanção disciplinar e “qual” aplicar, a natureza e os motivos da conduta do sentenciado, as circunstâncias em que se deu a ação, bem como suas consequências.

Sempre lembrando: que todo ATO ADMINISTRATIVO DEVE SER MOTIVADO, portanto, o Diretor deverá INDICAR os motivos de sua decisão considerando-se o caso concreto.

Vamos a um exemplo:

ABANDONAR O SERVIÇO é uma FALTA DISCIPLINAR.

1. MARIO ABANDONOU o serviço para ir FUMAR.

2. MARIO ABANDONOU o serviço porque teve uma desinteira (dor de barriga) muito forte e precisou usar o banheiro.

Considerando que o Diretor da Unidade deverá conhecer os MOTIVOS deste ABANDONO para a aplicação da sanção temos que, diante do exemplo acima, a MOTIVAÇÃO para reconhecimento e aplicação de uma SANÇÃO DISCIPLINAR, pelo Diretor da Unidade prisional NÃO poderá ser igual nas duas situações.

Obviamente que um motivo fisiológico não pode receber uma sanção tal qual o preso simplesmente abandonar seu posto de serviço para ir fumar um cigarrinho, na ora que bem lhe convier e sem autorização.

TRF-3 - REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL: RemNecCrim 50058867420224036119 SP. Acórdão publicado em 06/10/2022

Ementa: E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DESPROVIDO. 1. A reabilitação criminal alcança as penas impostas em sentença definitiva ao condenado em processo penal e garante o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação, podendo, ainda, atingir os efeitos da condenação previstos no art. 92 do Código Penal, observada a ressalva contida no art. 94, parágrafo único, do mesmo Diploma. 2. A reabilitação criminal tem natureza declaratória e vem disciplinada nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal. Os requisitos para que se declare a reabilitação de um condenado são cumulativos e estão elencados no artigo 94, CP: i. decurso do prazo de 2 anos do cumprimento ou da extinção da pena (computado o período de prova da suspensão e do livramento condicional, que não tenha sido revogado); ii. domicílio no país durante o prazo acima referido; iii. bom comportamento público e privado; iv. reparação do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo, ou renúncia da vítima ou novação da dívida. 3. No caso concreto, restaram devidamente comprovados os requisitos legais para deferimento do pedido de reabilitação, o qual se faz de rigor. No mesmo sentido foi o parecer lançado pela Procuradoria Regional da República. 4. Reexame necessário desprovido.

Assim, é extremamente importante o trabalho da DEFESA TÉCNICA na APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR em cada detalhe. Uma boa tese de defesa na DOSIMETRIA da aplicação da falta pode ensejar uma DESCLASSIFICAÇÃO da gravidade da falta.

Tenham sempre em mente: FALTA GRAVE é o Bicho Papão da EXECUÇÃO PENAL, porque PREJUDICA demais o Sentenciado, portanto, todo esforço deve ser feito para que a FALTA GRAVE NÃO SEJA RECONHECIDA!

Ementa: AGRADO DE EXECUÇÃO - Sindicância - Falta grave praticada em 23/09/2022 - Desobediência, consistente na recusa do sentenciado de ser transferido de pavilhão indicado pelos agentes penitenciários, alegando o desejo de ser transferido de unidade prisional. Pretende a defesa a desconstituição da falta disciplinar, diante da ausência de dolo do agravante - Sentenciado que não teve, em nenhum momento, a intenção de desobedecer aos funcionários ao solicitar transferência de unidade - PARCIAL PROVIMENTO - Falta grave não configurada - Não restou demonstrado que a conduta do agravante, embora com aparência de desobediência, configure comportamento que justificasse a classificação da falta como grave, vez que não abalou a disciplina ou a ordem do estabelecimento prisional, cuidando-se de fato isolado, que não causou maiores transtornos - Conduta que melhor se amolda à falta de natureza média, prevista no art. 45, incisos I e XX, do RIP. Agravo parcialmente provido.

FALTA DISCIPLINAR GRAVE

Cometer uma falta disciplinar grave na Execução Penal, acarreta inúmeras consequências para o sentenciado, tanto na esfera Administrativa (dentro da Unidade prisional), como na esfera Judicial (no que diz respeito à Execução Penal propriamente dita).

Sabe-se que, durante o cumprimento de pena, nossa legislação prevê vários benefícios aos SENTENCIADOS, com o intuito de RESSOCIALIZAÇÃO e EFETIVA retirada do Sentenciado da marginalidade, atendendo a propósitos de ressocialização, humanização e profissionalização.

Para tanto, é esperado uma CONTRAPARTIDA por parte destes SENTENCIADOS. E, quando eles DESCUMPREM alguma regra, cometendo uma FALTA DISCIPLINAR, especialmente as GRAVES, demonstram uma RELUTÂNCIA, especialmente, em sua própria REABILITAÇÃO, RESSOCIABILIZAÇÃO, sendo, assim, necessário que se promova PUNIÇÃO para que esta conduta NÃO esperada seja coibida de forma contundente.

Por isto, estas sanções, além de trazerem privações aos presos, afetam ou impossibilitam a conquista dos benefícios da execução da pena, que são previstos como um BENEFICÍO, mas o Sentenciado se mostrou inapto a ser merecedor.

Voltamos, assim, ao DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DO PRESO, especialmente ao DEVER DE DISCIPLINA, já esclarecido acima.

É preciso que fique claro que as tipificações, ou seja, a previsão do que é considerado FALTA GRAVE na EXECUÇÃO DA PENA deve constar EXPRESSAMENTE DE LEI, sendo, portanto, um ROL TAXATIVO.

Ao contrário do que acontece, com as FALTAS LEVES e MÉDIAS que possuem previsões em legislação local (cada unidade prisional possui as suas regras), bem como as respectivas sanções a serem aplicadas, conforme dispõe o Art. 59, caput da LEP:

Necessário observar que, não mais se distingue o tempo destinado a reabilitação entre reincidentes e não reincidentes, nem tão pouco o crime, ou crimes cometidos, isto é, se é hediondo ou não ou se foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Portanto, preenchendo os requisitos, a pessoa condenada e, portanto, com “FICHA SUJA” tem o direito à REABILITAÇÃO CRIMINAL, “limpando sua ficha”.

Trata-se, como já foi dito, de um DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA.

LEP. Das Faltas Disciplinares.

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.

Assim, HOJE nosso ordenamento jurídico prevê 9 (nove) MODALIDADES de FALTAS GRAVES, quais sejam:

1. incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina - LEP. Art. 50, I

2. FUGIR - LEP. Art. 50, II

3. possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem - LEP. Art. 50, III

4. provocar acidente de trabalho - LEP. Art. 50, IV

5. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas - LEP. Art. 50, V

6. Inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei - LEP. Art. 50, VI

7. tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo - LEP. Art. 50, VII

8. Descumprir as Regras das Penas Restritivas de Direito - LEP. Art. 51

9. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas - LEP. Art. 52

ATENÇÃO. As mesmas REGRAS relativas ao cometimento de FALTA GRAVE, se aplica aos PRESOS PROVISÓRIOS, nos termos do Parágrafo único do Art. 50, da LEP.

PRESOS PROVISÓRIOS são aqueles que AINDA não foram condenados definitivamente, ou seja, a SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO TRANSITOU EM JULGADO, portanto, possuem GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA e não GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA, isto é, estão presos aguardando julgamento.

No que se refere às faltas disciplinares dos sentenciados e respectivas punições, deve ser observado o princípio da reserva legal, ou seja, somente pode ser considerada infração aquela que estiver anteriormente prevista na lei ou regulamento, bem como só pode ser aplicada e executada a sanção anteriormente cominada para o fato.

Este princípio encontra-se no caput do art. 45 da LEP "(Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar)", como já citamos anteriormente.

Portanto, lembrem-se: SÓ AS 9 SITUAÇÕES ACIMA PODEM SER CONSIDERADAS COMO FALTA GRAVE E SÃO, PORTANTO, PASSÍVEIS DE SANÇÃO DISCIPLINAR, ADMINISTRATIVA E JUDICIAL!

TJ-SC - Agravo de Execução Penal: EP 50062684720218240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5006268-47.2021.8.24.0020. Acórdão publicado em 27/05/2021

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 50, INC. VI, C/C ART. 39, INC. II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DO REEDUCANDO. VIAS DE FATO ENTRE COLEGAS DE CELA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO APONTOU LESÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, ADEMAIS, PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. FATO QUE SE SUBSOME A CONTRAVENÇÃO PENAL E, POR ISSO MESMO, NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ART. 50 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO CASSADA. FALTA GRAVE DESCONSTITUÍDA.

"A prática de fato definido como contravenção penal não constitui falta grave nem autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, de modo que não pratica infração disciplinar dessa natureza o apenado que entra em vias de fato com outro detento, porque tal situação configura inobservância do dever de urbanidade e respeito previsto no art. 39, III, da Lei de Execução Penal, hipótese não elencada no rol taxativo das infrações disciplinares de maior intensidade (LEP, arts. 50 a 52)" (Agravo de Execução Penal n. 0000943-22.2020.8.24.0018, de Chapecó, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 3-11-2020). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como veremos mais à frente, o cometimento de FALTA GRAVE deve ser devidamente apurado pelo Diretor da Unidade Prisional, através da instauração de um PAD – Procedimento Administrativo Disciplinar, garantindo-se, ao Sentenciado os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, inclusive de ser assistido por Advogado/a para prestar a DEFESA TÉCNICA necessária.

Após a apuração e a decisão, por parte da Autoridade Administrativa, pelo RECONHECIMENTO da Falta Grave, será aplicada as SANÇÕES previstas e INFORMADO ao Juízo competente sobre os fatos que, também fará a devida APURAÇÃO JUDICIAL da Falta Disciplinar (Audiência de Justificativa) e aplicará, consequentemente, SANÇÕES DISCIPLINARES JUDICIAIS.

Assim, é preciso que fique claro que as SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e as SANÇÕES JUDICIAIS aplicadas em decorrência do cometimento de uma FALTA GRAVE são INDEPENDENTES.

LEGISLAÇÃO NA ÍNTEGRA:

LEP. Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso, ou condenado, à sanção disciplinar, sem prejuízo da sanção penal.

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

DAS ESPÉCIES DE FALTA GRAVE

É PRECISO QUE FIQUE CLARO QUE, TODAS AS CONDUTAS PREVISTAS COMO FALTA DISCIPLINAR GRAVE SÃO PUNÍVEIS TAMBÉM e DA MESMA FORMA, QUANDO TENTADAS, isto é, **nos termos do Art. 49, da LEP, a TENTATIVA é punida com a sanção correspondente à conduta consumada.**

TJ-SP - Agravo de Execução Penal: EP 44106220198260996 SP 0004410-62.2019.8.26.0996. Acórdão publicado em 13/06/2019

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Posse de aparelho celular - Absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Falta grave devidamente comprovada - Desnecessidade de perícia do objeto apreendido - Infração administrativa que dispensa laudo técnico - Autoria indubitosa - Elementos que indicam ter o réu solicitado a entrega do aparelho pelo seu pai, via 'sedex' - Tentativa de falta grave que é punida com a sanção correspondente ao fato consumado- Exegese do art. 49. p único, da LEP - Perda dos dias remidos justificada na gravidade da falta - Decisão incensurável - Recurso desprovido.

6.1. incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.

Previsto no Art. 50, I da LEP é considerada uma Falta extremamente grave por atentar, diretamente, contra a segurança dos estabelecimentos prisionais.

TJ-MG - Agravo em Execução Penal: AGEPN 10693170031647002 Três Corações. Acórdão publicado em 01/03/2023

Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINAR - FALTA GRAVE - RECONHECIMENTO - DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - 1. Na inteligência do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), comete falta grave o reeducando que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. 2. O depoimento dos agentes reveste-se de presunção de veracidade, suficiente para comprovar a prática da infração. 3. Na apuração de falta grave, as provas produzidas no procedimento administrativo, na presença de advogado constituído ou defensor público, podem ser utilizadas pelo juízo para o reconhecimento da prática de infração disciplinar.

* **INCITAR** = instigar, convencer, estimular os demais presos a praticar atos de subversão à ordem e à disciplina, podendo se dar através de conversas, discursos etc.

* **PARTICIPAR** = tomar parte e colaborar de forma efetiva, seja planejando ou praticando atos de violência ou indisciplina.

O exemplo mais clássico da hipótese acima é a ocorrência de motim, rebelião.

TJ-MG - Agravo em Execução Penal: AGEPN 10439150162790001 MG. Acórdão publicado em 19/08/2016

*Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A AGENTE PENITENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA - AUSÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO - **FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA** - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -Não demonstrado nos autos que a intenção do reeducando era a de descumprir uma ordem emanada por agente público por meio de um ato de indisciplina no presídio, tampouco praticar algum ato de subversão à ordem e a disciplina não há como reconhecer a falta grave - O reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica.*

TJ-SP - Agravo de Execução Penal: EP 158765320198260996 SP 0015876-53.2019.8.26.0996. Acórdão publicado em 20/03/2020

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Homologação de falta disciplinar de natureza grave em razão da apreensão de bilhete contendo graves ameaças à ordem e disciplina da unidade prisional. Absolvição por fragilidade probatória. Possibilidade. Ausência de laudo grafotécnico, ou qualquer prova, a comprovar a autoria do manuscrito. Infração não comprovada. Afastamento da falta grave que se impõe. Recurso provido.

OBSERVAÇÃO. Não se CONFUNDE a falta grave prevista no inciso I do Art. 50, com o CRIME DE MOTIM previsto no Art. 354, do Código Penal.

A principal diferença que deve ser observada é que para que se configure a falta grave NÃO se exige o DOLO, que é exigido para a tipificação do crime de motim previsto no CP.

Mas é importante que fique claro que esta Falta disciplinar também poderá caracterizar o cometimento de crime. E aplicação de sanções administrativas NÃO dependerá da apuração do crime, que é feito na esfera Judicial.

TJ-MG - Apelação Criminal: APR 10499120032945001 MG. Acórdão publicado em 08/09/2014

Ementa: APELAÇÃO. MOTIM DE PRESOS. DELITO MULTITUDINÁRIO. INADEQUAÇÃO TÍPICA NO CASO CONCRETO. APENAS TRÊS AGENTES QUE CONCORRERAM PARA A AÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE E CONSCIÊNCIA DE PROVOCAR PERIGO PARA UM NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS E PATRIMÔNIOS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS. PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL. Para a caracterização do delito de motim de presos é necessário que concorram vários agentes, tendo em vista seu caráter multitudinário, não bastando a ação de apenas três detentos. O objeto jurídico do crime de incêndio é a incolumidade pública, isto é, a segurança e a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas. Assim, para sua caracterização, não basta que os agentes tenham ateado fogo em algum objeto, provocando a destruição de parte de algum patrimônio. Efetivamente, é necessário que os agentes tenham agido imbuídos de vontade e consciência de causar perigo efetivo ou concreto para pessoas ou coisas indeterminadas.

TJ-RO - Agravo de Execução Penal: EP 54224520158220000 RO 0005422-45.2015.822.0000. Acórdão publicado em 03/08/2015

Ementa: Agravo em execução penal. Motim. Participação. Provas. Ausência. Elemento subjetivo. Inexistência. Falta grave. Inocorrência. Agravo não provido. Quando ausentes provas da participação efetiva do apenado, bem como da existência do elemento subjetivo do crime de motim de presos, caracterizado pela vontade dos presos de se amotinarem, cientes de que estão agindo para tumultuar a ordem e a disciplina do estabelecimento penal, não se conhece da falta grave.

*** TESE DE DEFESA**

Uma das principais teses de DEFESA a ser utilizada pelo Advogado ou advogada que tenha um cliente em apuração com relação a esta FALTA GRAVE, é a alegação de INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, que gera a excludente de culpabilidade. Ou seja, provar que seu cliente NÃO poderia agir de outra forma, porque estava, de alguma forma, OBRIGADO por algum ou alguns outros presos.

6.2. FUGA

A falta Disciplinar Grave de FUGA, está prevista no Art. 50, II da LEP e gera uma efetiva quebra de confiança do estado para o preso/sentenciado no cumprimento de sua reprimenda.

Além disso, NÃO FUGIR está previsto como um dos DEVERES DO PRESO, Art. 39, IV da LEP, o que torna, ainda mais reprovável a conduta.

Sobre a FUGA é necessário observar que será considerado FUGA, tanto a evasão de dentro da Unidade prisional, quanto de fora, isto é, quando o sentenciado está em gozo de saída temporária ou exercendo trabalho externo, por exemplo.

É preciso, ainda, que o Advogado e a Advogada atuante na execução Penal se atente para a diferenciação entre FUGA e o ATRASO PARA RETORNO do sentenciado e RETORNO TARDIO ESPONTÂNEO.

Está diferenciação será de extrema importância na DEFESA de seu cliente quando da apuração da falta grave e, consequentemente, na aplicação de SANÇÕES DISCIPLINARES, tanto administrativas quanto judiciais, inclusive para uma DESCLASSIFICAÇÃO para Falta menos gravosa.

TJ-DF - 7150895520208070000 DF 0715089-55.2020.8.07.0000. Acórdão publicado em 01/10/2020

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SENTENCIADO QUE NÃO RETORNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS GOZO DE BENEFÍCIO EXTERNO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE SE EVADIR. FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Restando duvidoso o animus de evasão do sentenciado, que não retorna ao estabelecimento prisional após o gozo de benefício externo, mas se apresenta espontaneamente no dia seguinte, correta a decisão que desclassifica a falta grave para média. 2. Além de não restar evidenciada a intenção de fuga, o reconhecimento de falta grave, com a consequente regressão de regime e perda dos dias remidos, revela-se desproporcional à conduta em questão, a qual melhor se enquadra à falta média descrita no artigo 119, XVIII, do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do DF - "ausentar-se dos lugares em que deva permanecer". 3. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

Nos vamos ter o ATRASO PARA RETORNO quando o Sentenciado se atrasa em algumas horas para o reingresso na unidade prisional após uma saída temporária, por exemplo, sob alegação de um pneu furado, uma enchente que atrasou a partida dos ônibus etc. Nestes casos, você vai pugnar pela NÃO classificação como FALTA GRAVE, arguindo a JUSTA motivação e explicação apresentada pelo sentenciado. Devendo ser, portanto, classificada como uma FALTA LEVE ensejando sanção de ADVERTÊNCIA, por exemplo.

Já o RETORNO TARDIO ESPONTÂNEO se dá quando, por exemplo, o sentenciado demora alguns dias para retornar de uma “saidinha”, mas se apresenta espontaneamente.

TJ-RS - Agravo: AGV 70071701205 RS. Acórdão publicado em 20/01/2017

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OBSERVADO. FALTA GRAVE. FUGA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. FALTA GRAVE AFASTADA. 1. Para a análise da ocorrência de falta grave é necessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, o qual deve ser remetido ao Juízo de Execução, que determinará a audiência de justificação prevista no artigo 118, § 2º, da LEP. No caso dos autos, o procedimento foi corretamente observado. 2. Uma vez que houve apresentação espontânea pouco mais de uma hora após o horário previsto para que retornasse à casa prisional depois do término da saída temporária, tenho que a justificativa do apenado é plausível e cabe ser acolhida, afastando-se o reconhecimento da prática de falta grave e as demais sanções impostas pelo Juízo a quo. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. FALTA GRAVE AFASTADA.

OBSERVAÇÃO. NÃO se confunde a falta disciplinar de FUGA com o CRIME DE EVASÃO, previsto no Art. 352, do Código Penal. Neste é exigível a CONDUTA = VIOLÊNCIA para sua tipificação.

Ou seja, se na FUGA do preso ele comete VIOLÊNCIA, ALÉM de caracterizar uma FALTA GRAVE, será CARACTERIZADO um CRIME próprio, autônomo, pelo qual responderá judicialmente o sentenciado.

6. 3. possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem

Prevista no Art. 50, III da LEP, a hipótese acima é abrangente, podendo englobar quaisquer objetos tradicionalmente usados ou fabricados para ferir, os conhecidos “estoques”, que são instrumentos artesanais, construídos pelos presos, consistentes em ter uma ponta afiada, capaz de perfurar, furar, ofender a integridade física de alguém.

A mera POSSE já configura a falta grave, não precisando que o preso esteja usando, ameaçando alguém no momento de sua apreensão.

Entretanto é importante que se observe que a APREENSÃO DO OBJETO é INDISPENSÁVEL para a caracterização da falta disciplinar, assim como o conhecimento da AUTORIA da posse, isto é, a quem pertence.

A autoria é de grande relevância na apuração da falta, especialmente para a defesa já que, na grande maioria das vezes, estes instrumentos são encontrados pelos agentes penitenciários dentro da cela, onde convivem vários presos, coletivamente.

OBSERVAÇÃO. Se exige a apreensão do objeto mas não sua pericia, para conhecer da efetiva lesividade ou não do objeto.

STJ - HABEAS CORPUS: HC 476948 DF 2018/0288899-4. Acórdão publicado em 19/02/2019

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. ART. 50, III, DA LEP. APREENSÃO DE INSTRUMENTO PÉRFURO-CORTANTE EM PODER DO SENTENCIADO. "ESTOQUE" DE 20 CM. PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Segundo entendimento firmado nesta Corte, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização pericia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal. III - No caso, foi apreendido em poder do paciente um "estoque" - instrumento artesanal pontiagudo, confeccionado em vergalhão de aço - de 20 vinte) centímetros", que é apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal. Habeas corpus não conhecido.

6.4. provocar acidente de trabalho

Prevista no Art. 50, IV esta falta é tipificada quando um preso, dolosamente, se machuca, se acidenta, ou provoca um acidente que acarrete a integridade física de outros presos, durante a execução do trabalho a que esta submetido.

É muito importante que aqui se observe a necessidade da comprovação do DOLO, já que, acidentes acontecem e, portanto, NÃO é qualquer acidente que pode levar à punição do Sentenciado.

OBSERVAÇÃO. A LEI não faz distinção entre o trabalho ser interno ou externo.

Nem tampouco se exige um DANO MATERIAL/PATRIMONIAL para a configuração da falta grave.

6.5. descumprir, no regime aberto, as condições impostas

Previsto no Art. 50, V, DESCUMPRIR as regras impostas ao cumprimento de sentença no REGIME ABERTO é considerado FALTA DISCIPLINAR GRAVE.

As condições LEGAIS impostas ao cumprimento do REGIME ABERTO, estão previstas no Art. 115 da LEP:

Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Além destas CONDIÇÕES LEGAIS, impostas igualmente a qualquer preso em cumprimento no regime aberto, temos as CONDIÇÕES JUDICIAIS, que são impostas, individualmente a cada preso.

Como, por exemplo: não frequentar determinados lugares especificados pelo Juízo da Execução.

Assim como a própria previsão de quanto em quanto tempo deverá o sentenciado comparecer em cartório para “assinar a carteirinha” pode ser diferenciado para cada sentenciado, de acordo com a determinação judicial.

TRF-4 - Agravo de Execução Penal: EP 50027973820224047017. Acórdão publicado em 22/11/2022

Ementa: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. VIOLAÇÕES INJUSTIFICADAS AO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DESPROPORCIONALIDADE À VISTA DAS PECULIARIDADES DO CASO. SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA. 1. É inexorável que o apenado, não obstante encontrar-se em regime aberto, tem efetivas limitações à sua liberdade e, por conseguinte, eventual mudança de endereço deve ser precedida de comunicação ao juízo. 2. Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas como, no caso, de não recolhimento domiciliar no dia e hora determinados pelo juízo, e mudança de endereço, sem a devida e prévia comunicação ao Juízo da Execução Penal. 3. A despeito do cometimento das faltas graves, em face da quantidade remanescente de pena e da inexistência de outras faltas ou elementos desabonadores no curso da execução, o sancionamento da falta grave com a imediata regressão de regime viola a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se suficiente a imposição da penalidade de advertência.

OBSERVAÇÃO. A lei prevê a existência de albergue especial para recolher em período noturno os apenados com regime aberto, estabelecimentos estes que foram escassamente construídos, o que leva, portanto, aos presos em cumprimento do regime aberto, ficarem, em verdade, em regime domiciliar. O que não exclui, de forma alguma, sua obrigação de cumprimento das determinações legais e judiciais importas.

6.6. inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei

Os incisos mencionados acima tratam do dever do condenado de agir com obediência ao servidor, respeito com as pessoas em geral e urbanidade com demais condenados e conduta oposta à fuga ou subversão da ordem e disciplina.

Relembrando:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 779490 SC 2022/0337583-5. Acórdão publicado em 31/05/2023

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERDA DE 1/4 DE DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. NOVA FALTA GRAVE COMETIDA POSTERIORMENTE. EVASÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos. 2. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave (art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP). 3. Ademais, no caso concreto, está justificada a perda de dias remidos no percentual de 1/4, por ter o apenado retornado com atraso da saída temporária que lhe fora concedida. Ressalte-se, ainda, que, posteriormente, não retornou da benesse da saída temporária em 28/2/2020, vindo a ser recapturado tão somente em 16/9/2021.3. Agravo regimental improvido.

DICA! É importante que o Advogado e Advogada atuante na Execução Penal se atente às diversas possibilidades de a Unidade Prisional caracterizar a DESOBEDIÊNCIA do preso com a finalidade de aplicação de falta grave. Assim, estar preparado para apresentação de boas teses de defesa é importante e a LEITURA e ESTUDO de JURISPRUDÊNCIAS é de grande valia neste aprendizado e aprofundamento técnico.

A leitura de Jurisprudências nos traz casos diversificados com o apontamento de boas teses defensivas.

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. DESOBEDIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA ORIGEM PARA FALTA LEVE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a conduta imputada ao sentenciado, que permaneceu fora de sua cela, transitando indevidamente pelo Pátio de Sol após o fechamento das portas das celas que sucede ao banho de sol, enquadrou-se na prevista no artigo 44, I, do RIP/SAP, e não se revestiu dos elementos necessários a caracterizar desrespeito ou desobediência, mostra-se correto e proporcional o reconhecimento da falta leve prevista no artigo 44, I, do RIP/SAP, consistente em transitar indevidamente pela unidade prisional, como bem decidido pelo MM. Juízo a quo. 2. No caso dos autos, ao término do banho de sol e do procedimento de fechamento automático das celas do 1º Pavilhão Habitacional, o sentenciado permaneceu fora da cela, andando pelo Pátio de Sol, e, advertido de sua conduta, pediu ao funcionário que o mudasse de pavilhão, pois se desentendera com um sentenciado que habitava a mesma cela que ele, esclarecendo que não voltara à sua cela visando garantir sua integridade física. 3. A ausência de elementos probatórios a indicar a efetiva ocorrência da desobediência, ante a comprovação apenas da permanência do sentenciado transitando indevidamente pela unidade prisional, após fechamento automático das portas das celas, justifica a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza leve, tal como operado na origem, mostrando-se correta, pois, a respeitável decisão judicial recorrida. 4. Agravo ministerial desprovido.

6.7. tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Neste caso de falta grave, é imperioso que se observe que, caracteriza falta grave também a posse de bateria e acessórios de celular, como chips e outros componentes.

Em verdade, podemos dizer qualquer “peça” de aparelho celular ou rádio de comunicação que, quando, “juntado” a outros funcione e dê ao preso a possibilidade de comunicação externa.

E, assim como no caso de outras faltas graves, não se exige na apuração da falta disciplinar a realização de PERÍCIA que ateste a funcionalidade do aparelho celular ou viabilidade de funcionalidade de apetrechos (componentes) apreendidos.

*Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE E REVOGOU 1/9 DOS DIAS REMIDOS. INSURGÊNCIA POR PARTE DO APENADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DO AGENTE PENITENCIÁRIO, ALIADA À ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DOS OBJETOS, PELO REEDUCANDO, NO TERMO DE APREENSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. FALTA GRAVE CARACTERIZADA A TEOR DO ARTIGO 50 , INCISO VII DA LEI DE EXECUCOES PENAIS . DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO MÉDIA INVIABILIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Os elementos colhidos nos autos são harmônicos no sentido de que o apenado estava na posse de aparelho celular dentro do estabelecimento penal, caracterizando a falta grave tipificada no artigo 50, inciso VII da Lei de Execução Penal. II - Destaque-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, os agentes públicos são detentores de fé pública, havendo, portanto, presunção de veracidade da declaração por eles prestadas, especialmente quando ausente qualquer indício em sentido contrário, como é o caso dos autos. III - Embora o agravante tenha negado a propriedade do aparelho celular no procedimento administrativo, certo é que o objeto foi apreendido em sua cela e ele mesmo assumiu ser o responsável pela posse, conforme assinatura do termo de apreensão, corroborada pelo depoimento do agente penitenciário, configurando a falta grave homologada. IV - A mera posse ou utilização de aparelho telefônico que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo caracteriza falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII da Lei de Execução Penal. Assim, definida que a posse do aparelho de telefone celular caracteriza falta grave, independentemente de prova de sua prestabilidade, inviável a pretensa desclassificação para falta média. (TJPR - 4º C.Criminal - 4000299-26.2022.8.16.0030 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 06.06.2022)*

Existindo, entretanto, precedentes em sentido diverso, que consideram o cabo USB, o fone de ouvido e microfone não são acessórios essenciais ao funcionamento de aparelho de telefonia celular ou rádio de comunicação e, portanto, não se amoldariam à finalidade da norma prevista no art. 50, VII, da Lei 7.210/1984, não devendo sua posse implicar falta grave.

Portanto é necessária atenção do advogado e da advogada para uma defesa combativa a fim de conseguir a NÃO aplicação de falta grave ao cliente nestes casos.

Preciso ainda lembrar, sobre esta questão, que a pessoa que entra com aparelho/equipamento de comunicação dentro de uma unidade prisional comete CRIME, previsto no Art. 349-A do Código Penal, com pena de detenção prevista de 3 (meses) a 1 (hum) ano.

Assim também, o Código Penal prevê, em seu Art. 319-A que será punido o DIREITOR DA UNIDADE PRISIONAL e o AGENTE PÚBLICO que não IMPEDIR A ENTRADA destes equipamentos na prisão, considerando que, assim o fazendo, estão DEIXANDO DE CUMPRIR COM SEU DEVER DE VIGIÂNCIA, DE VEDAÇÃO do acesso dos presos à comunicação externa indevida.

OBSERVAÇÃO: Estamos falando aqui de COMUNICAÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZADA. Porque é preciso que se entenda que é DIREITO DO PRESO COMUNICAR-SE COM O MUNDO EXTERNO, como por exemplo, ocorre com as correspondências.

Mas, a comunicação por aparelhos telefônicos ou rádios de comunicação e, em qualquer horário e, sem supervisão, NÃO é permitido.

Portanto, NÃO É a COMUNICAÇÃO EXTERNA que é proibida e sim, A COMUNICAÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZADA.

6.8. recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Por fim, também é considerada falta grave, previsto no Art. 50 da LEP, a recusa ao procedimento de identificação do perfil genético obrigatório.

Este inciso foi inserido recentemente, através do PACOTE ANTI-CRIME – Lei n. 13.964/19, e está previsto no art. 9º-A da LEP, a aplicação nos crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa ou nos crimes hediondos.

Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional.

§ 1º A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense.

§ 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético.

§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa.

§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena.

§ 5º A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar.

§ 6º Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim.

§ 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial.

§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Este assunto tem sido, incisivamente, debatido no mundo jurídico, especialmente pelos que defendem tratar-se, tal dispositivo de inconstitucional por ferir o princípio da NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO assegurado aos indivíduos. Mesmo considerando-se que não são TODOS os presos que estão submetidos a esta obrigatoriedade, conforme se verifica pelo artigo acima.

Este tema esta em discussão no STF devendo, portanto, o Advogado e a Advogada ficar atento á solução da celeuma em seu entorno, quando da aplicação, em concreto, no caso de um cliente.

6.7. tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Prevista no Art. 52 da LEP, constitui **FALTA GRAVE**, o cometimento de **NOVO CRIME DOLOSO**:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Neste caso é preciso atenção especial para o fato de que a lei fala expressamente sobre o **cometimento de NOVO CRIME DOLOSO, portanto, CONTRAVENÇÕES PENAIS e CRIMES CULPOSOS NÃO podem ser considerado como cometimento de FALTA GRAVE.**

Outro ponto importante é que a lei **NÃO** exige para que o preso possa ser sancionado com o reconhecimento da falta grave em questão, que exista uma **SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO**.

OU SEJA, ABSURDAMENTE, o simples fato de um sentenciado, que se encontra cumprindo pena no regime aberto, por exemplo, e é preso em flagrante delito, por **SUSPEITA** do cometimento de um **CRIME DOLOSO**, já será o suficiente para que lhe seja imposta sanções administrativas e judiciais pelo reconhecimento do cometimento de uma **FALTA GRAVE**.

OBSERVAÇÃO PESSOAL. No meu entendimento, é um absurdo jurídico, totalmente em descompasso com um princípio **BASILAR** do **DIREITO PENAL**: a presunção de inocência! E deixo aqui, registrado minha indignação-jurídica.

Se existe um “pecado” jurídico na Lei de Execução Penal, certamente, este é o mais “gritante”.

Enfim, seguimos, nós, Advogados e Advogadas criminalistas, com atuação na execução criminal, lutando para que seja reconhecida esta inconstitucionalidade. Nunca deixe de protestar e recorrer sobre este tema, mesmo com jurisprudências em contrário!

Voltando ... Mais do que jurisprudências em contrário, na verdades esta questão já está SUMULADA pelo STF:

STJ. SÚMULA 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Em sendo o sentenciado, **POSTERIORMENTE, ABSOLVIDO**, pelo fato que gerou o reconhecimento de FALTA GRAVE e, conseqüentemente, aplicação de SANÇÕES DISCIPLINARES, ou tenha sido reconhecida **EXTINÇÃO D EPUNIBILIDADE** ou **ARQUVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL**, deverá ser formulado uma pedido ao **JUÍZO DA EXECUÇÃO** para que **DESCONSidere A FALTA GRAVE, REVOQUE AS SANÇÕES APLICADAS, APAGUE AS ANOTAÇÕES** CONTRÁRIAS ao sentenciado, relativos a este evento, devendo voltar, o Sentenciado, ao status quo antes de tal decisão administrativa e judicial em desfavor ao sentenciado, na Execução Penal.

TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Agravo de Execução Penal: AGV. 2747520208090000 GOIÂNIA. Acórdão publicado em 23/03/2021

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO DE REGIME E OUTROS EFEITOS. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO CRIME ENSEJADOR DA FALTA GRAVE. REVERSÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. Inobstante respeitada a autonomia entre as esferas administrativa, civil e penal, não pode subsistir o reconhecimento de falta disciplinar grave decorrente de suposta prática de novo crime do qual supervenientemente o reeducando logrou absolvição. Precedentes do TJGO e STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS: AgRg nos EDcl no HC 601533 SP 2020/0189962-2. Acórdão publicado em 01/10/2021

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA MITIGADA DAS INSTÂNCIAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria. 2. Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa. Precedente. 3. Em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias. 4. Agravo regimental provido a fim de determinar o cancelamento da falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 41/2017 (E-21/934137/2011) e de todos os efeitos dela decorrentes.

PAD – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA COMETIDA POR SENTENCIADO

Como vimos acima, para o RECONHECIMENTO da PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR na EXECUÇÃO PENAL é imprescindível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo diretor do presídio.

LEP. Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para a sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.

E, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como proclamar seu reconhecimento, verificar se a conduta é corresponde a uma falta leve, média ou grave e aplicar as respectivas sanções disciplinares, é do diretor do presídio, que é o detentor do poder disciplinar.

LEP. Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.

Deve ser assegurado, durante todo o procedimento do PAD, ao Sentenciado, o direito à ampla defesa e ao contraditório, a ser exercido por advogado constituído ou defensor público.

O STJ, editou a súmula 533, deixando bastante claro a necessidade da obrigatoriedade da instauração do PAD:

STJ. SÚMULA n. 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

A análise administrativa se dá através de um Processo Administrativo Disciplinar, conhecido como PAD. A instauração de um PAD, em regra, advém de um Boletim de Ocorrência (apontando a prática de um crime doloso), de um termo de ocorrência circunstanciado no próprio estabelecimento prisional (no momento em que se localiza um aparelho telefônico, por exemplo) ou através de cópia de livro atestando que o apenado não retornou de alguma saída temporária (acrescida também de um termo de ocorrência).

O rito ou procedimento do PAD estará previsto em normas locais, isto é, no estatuto de cada Unidade Prisional, bem como em Leis Estaduais, portanto, próprias de cada estado da federação.

Observação.1:

Sabe-se que, no processo penal nos temos, sempre o INTERROGATÓRIO da pessoa acusada como último ato, exatamente como uma forma de assegurar a AMPLA DEFESA.

Entretanto, nossos Tribunais têm entendido que, no PAD está sequência não é obrigatória, não gerando nulidade ou ferindo direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, sendo exigido, tão somente, a presença do ADVOGADO/A.

Sendo certo que, no processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave no curso da execução penal, a inexistência de defesa técnica por advogado, inclusive, na oitiva de testemunhas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando causa de nulidade do PAD.

(...) na execução da pena está em jogo a liberdade do sentenciado, o qual se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, revelando-se incompreensível que ele possa exercer uma ampla defesa sem o conhecimento técnico do ordenamento jurídico, não se podendo, portanto, equipará-lo ao indivíduo que responde a processo disciplinar na esfera cível-administrativa. Dessa forma, no âmbito da execução penal, deve ser garantido o pleno direito de defesa ao detento, com a presença de advogado constituído ou defensor público nomeado, por ocasião de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave.

Ministro Marco Aurélio Bellizze

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. OCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA IMPUTADA. MENÇÕES GENÉRICAS A DILIGÊNCIAS. IN DUBIO PRO REO. HOMOLOGAÇÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. NEGATIVA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente firme acervo probatório para se evidenciar, em inquérito disciplinar, a autoria da falta grave imputada ao agravado, correta a não homologação por parte do d. juízo a quo, sob pena de violação direta do princípio do in dubio pro reo. 2. Agravo em execução penal conhecido e não provido.

Portanto, Advogada e Advogado, é sempre importante, quando você assume a Execução Penal de um cliente que possui o reconhecimento de FALTA GRAVE, verificar se o PAD foi conduzido de forma a respeitar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Caso contrário, você pode ajuizar pedido de NULIDADE e, assim, todo o procedimento, bem como as sanções impostas serão retiradas, voltando seu cliente, ao status anterior da Execução Penal.

LEMBRE-SE: Todos os atos que, por sua natureza, admitem o contraditório e a ampla defesa, devem ser praticados na presença do/a advogado/a do condenado

A própria LEP prevê, em seus os artigos 15, 16 e 83, § 5º, justamente a obrigatoriedade de instalação da Defensoria Pública nos estabelecimentos penais, a fim de assegurar a defesa técnica daqueles que não possuem recursos financeiros para constituir advogado/a.

O ADVOGADO É INDISPENSÁVEL À JUSTIÇA!

Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO. Para que se reconheça a prática de falta grave, é preciso que as provas colhidas em sede administrativa sejam produzidas sob o crivo do contraditório, sob pena de absolvição. A ausência de provas que atestem a prática de falta grave pelo apenado exige sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.

E é preciso dizer, ainda, que a expressa exigência de um advogado ou defensor veda que o apenado seja assistido por um assistente judiciário do próprio estabelecimento prisional, já que, por uma questão de hierarquia, esses assistentes são subordinados ao diretor do estabelecimento, que é quem atestará, nessa fase, se houve ou não o cometimento de falta disciplinar.

Observação. 2. :

No que diz respeito ao PAD, para apuração de Falta Disciplinar cometida pelo sentenciado, é pacífico em nossos tribunais que, a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento, tanto para o diretor da unidade prisional, como para o magistrado, considerando-se que, tratam-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

“Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 562.216/SP, j. 26/05/2020).

Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECONHECIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS TESTEMUNHOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ELEIÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO. PRECEDENTES. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade" (AgRg no HC 550.514/SP , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). 2. A rigor, o pretendido afastamento da falta grave em razão da alegada irregularidade no reconhecimento da autoria e materialidade não pode ser analisado. Na via eleita, por sua estreiteza, não é possível o revolvimento de fatos e provas. Precedentes. 3. A perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave não pressupõe a adoção objetiva da razão de 1/3 (um terço), que se trata de limite máximo para o decréscimo. Cabe ao Juízo das Execuções, com discricionariedade regrada, fundamentar a escolha do quantum de perda, consideradas "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", nos termos do art. 57 da Lei de Execuções Penais . 4. Ao decotar 1/3 (um terço) dos dias remidos, o Magistrado de primeiro grau - corroborado pelo Tribunal local - lastreou-se tão somente na gravidade abstrata da conduta e no sentimento de impunidade, que consubstanciam fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro procedimento, e que, portanto, não são idôneos para justificar a eleição da maior razão, possível somente à luz de dados categóricos constantes nos autos. Dessa forma, não se declinou motivação material, com base em elementos concretos dos autos, ao eleger-se o patamar máximo previsto em lei; ou seja, as instâncias ordinárias não observaram o dever constitucional de fundamentar. 5. O art. 127 da Lei de Execução Penal prevê que "[e]m caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57 , recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar". Nessa hipótese, a perda dos dias remidos consubstancia medida impositiva. Doutrina (AVENA, Norberto: Execução Penal, 6.º ed.; Rio de Janeiro: Forense, 2019). Precedentes: STJ, REsp n. 1.424.583/PR , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 18/6/2014; STJ, AgRg no REsp 1431121/PR , Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018. 6. A Legislação indica apenas o limite máximo para a penalidade. Por outro lado, embora seja corolário legal da prática de falta grave a perda de dias remidos, não há a cominação abstrata da fração mínima. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que tal estipulação seja procedida pelo Juiz das Execuções Criminais. 7. A propósito, quanto à ausência de motivação para a escolha do patamar para a remição, Guilherme de Sousa Nucci leciona que "não pode o Tribunal sobrepor-se à falha do magistrado, fornecendo a justificativa cabível para manter ou reformar o decisum, sob pena de supressão de instância" (in Curso de Execução Penal, 4.º ed.; Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 213). 8. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de habeas corpus parcialmente concedida para determinar ao Juiz das Execuções Criminais que fixe o patamar para a perda dos dias remidos de modo fundamentado, à luz da disciplina do art. 127 da Lei de Execução Penal , afastado o estabelecimento no máximo legal.

OBSERVAÇÃO. 3.:

É preciso que o Advogado e Advogada atuante na Execução Penal LEMBRE-SE que PODEM SER ARROLADAS TESTEMUNHAS para serem ouvidas no PAD, juntada de provas e, inclusive, pedidos de diligências e perícias. E isto pode ser o diferencial para a DEFESA do seu cliente.

Faz parte do direito de ampla defesa e contraditório e, portanto, deve ser assegurada ao Sentenciado.

OBSERVAÇÃO. 4:

Conforme veremos à frente, a realização de perícia não é exigida nos casos de aparelhos celulares, componentes ou rádios de comunicação, assim como em instrumentos considerados como passíveis de ferir outrem. Isto porque, já é pacífico em nossos Tribunais esta desnecessidade para a configuração da Falta grave.

Entretanto, o mesmo NÃO OCORRE, por exemplo, nos casos de LESÃO CORPORAL, em que o EXAME DE CORPO DE DELITO deve ser considerado imprescindível para a culpabilização do sentenciado.

Mas é preciso que, nestes casos, estejamos diante de um CRIME, de LESÃO CORPORAL, e, portanto, está apuração e, consequentemente, a perícia, deve ser realizada em sede policial, isto é, através de um Inquérito Policial.

Assim também se dará no caso em que o Cliente for pego na POSSE DE DROGAS. O laudo pericial para a comprovação da substância, também será IMPRESCINDÍVEL.

Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTAS GRAVES - POSSE DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL E DESRESPEITO À ORDEM EMANDA DO AGENTE PENITENCIÁRIO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO DE POSSE DE DROGAS POR FALTA DO EXAME TOXICOLÓGICO - PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Para o reconhecimento da falta grave consistente na posse de drogas, prescindível a confecção do referido laudo toxicológico, bastando a existência de elementos suficientes acerca da transgressão disciplinar, sendo que, a efetiva caracterização do crime deverá ser apurada na Justiça Criminal. 2. Por outro lado, verifica-se que a conduta do apenado apurada judicialmente não se limitou a apurar tão somente a posse de drogas, mas também o desrespeito à ordem emanada do policial penal, incorrendo, portanto, no art. 50 , inciso V c/c art. 39 , incisos II e V , ambos da LEP . 3. Dessa forma, restando devidamente comprovado nos autos o envolvimento do reeducando com os fatos que lhe foram imputados, tendo ele demonstrado senso de indisciplina e irresponsabilidade para o cumprimento de sua pena, imperiosa a manutenção da decisão que reconheceu a prática das faltas graves. V.V. A ausência de realização de exame toxicológico para o reconhecimento de falta grave decorrente da suposta prática de crime relacionado à posse de substância entorpecente obsta o reconhecimento da falta grave, uma vez que ausente prova da materialidade.

• CONTROLE DA LEGALIDADE

Por último, é preciso dizer que, a decisão proferida pela autoridade administrativa prisional em processo administrativo disciplinar – PAD que apura o cometimento de falta grave disciplinar no âmbito da Execução Penal é ato administrativo, portanto, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, exercido, nestes casos, pelo Juízo da vara de execuções penais e Vara da Corregedoria dos Presídios.

Ressaltando-se, entretanto, que o entendimento majoritário é que o condenado deve se defender dos fatos, e não da natureza legal da falta cometida. Assim, é possível que o juiz da execução, zelando pela correta aplicação da lei, faça o controle da decisão administrativa, justificando tal assertiva no Art. 66, VI da LEP, onde deve ser incluída a APRECIÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS em sede administrativa, isto é, pelo Diretor da Unidade Prisional.

"(...)Assim, ainda que se reconheça certa discricionariedade da autoridade administrativa prisional no exercício de dosimetria da penalidade administrativa – conforme previsto no art. 59 da LEP -, não se pode admitir a convalidação dessa atividade em arbitrariedade e, ainda, retirar do Poder Judiciário a devida intervenção" (HC 365.431/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 8/11/2016)" (AgRg no AREsp 1.439.580/SP, j. 15/10/2019).

OU SEJA, o JUDICIÁRIO NÃO INTERFERIRÁ no MÉRITO da apuração da Falta Grave em si, MAS, tão somente, no que diz respeito à LEGALIDADE DO ATO, isto é, se foram respeitadas a legalidade e constitucionalidade da apuração disciplinar, se foram respeitados os princípios administrativos da razoabilidade e proporcionalidade.

TJ-SC - Agravo de Execução Penal: EP 50450463220218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5045046-32.2021.8.24.0038. Acórdão publicado em 14/12/2021

Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RÉU PRESO - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE NÃO HOMOLOGA FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR - POSSE DE DROGAS (LEP, ART. 52, CAPUT)- COMPETÊNCIA DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL PARA RECONHECER A FALTA GRAVE - ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado no tema n. 652 dos recursos repetitivos, "no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde à uma falta leve, média ou grave, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar" (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze). Ao Judiciário, portanto, cabe apenas aferir a legalidade do procedimento e, se for o caso, aplicar as sanções que exigem observância à cláusula de reserva de jurisdição. PROCEDIMENTO QUE OBEDECE AS FORMALIDADES IMPOSTAS - AGRAVADO QUE EXERCE PLENA DEFESA NO PAD E É ACOMPANHADO DE DEFENSOR DURANTE A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DECISÃO DO DIRETOR DO PRESÍDIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE QUE SE FAZ NECESSÁRIA - DECISÃO REFORMADA. Não havendo ilegalidades no procedimento administrativo disciplinar e nos atos e decisões proferidas pelo diretor do ergástulo público, deve-se homologar a falta grave praticada por detento. PEDIDOS SUCESSIVOS DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - NÃO CONHECIMENTO - EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR A SEREM APLICADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

APURAÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE

É OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO APURADA UMA FALTA GRAVE!

LEP. ART. 48. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei.

ENCERRADO O PAD, reconhecida a falta disciplinar grave na fase administrativa, o diretor do estabelecimento prisional rebaixa o comportamento do apenado, fazendo o registro da falta apurada e encaminha ao juízo da execução um relatório com as conclusões do processo administrativo, para apreciação, apuração e aplicação, quando o caso, de SANÇÕES DISCIPLINARES JUDICIAIS.

“(...) a Lei de Execução Penal não deixa dúvida ao estabelecer que todo o "processo" de apuração da falta disciplinar (investigação e subsunção), assim como a aplicação da respectiva punição, é realizado dentro da unidade penitenciária, sendo de responsabilidade do seu diretor, porquanto é quem detém o exercício do poder disciplinar. Somente se for reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo diretor do estabelecimento prisional, é que será comunicado ao juiz da execução penal para que aplique determinadas sanções, que o legislador, excepcionando a regra, entendeu por bem conferir caráter jurisdicional.”

Ministro Marco Aurélio Bellizze

Inicia-se, assim, a HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL da Falta Disciplinar Grave do Sentenciado.

O Ministério Público será intimado para se manifestar, seguido da DEFESA que apresentará defesa e pedidos preliminares, inclusive, podendo pedir produção das provas que entender necessárias.

O juiz analisará os pedidos, tanto do Ministério Público quanto da defesa e designará uma AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.

Na sequência, novamente Ministério Público e Defesa se pronunciam, apresentando as ALEGAÇÕES FINAIS, seguindo-se à decisão do Juízo, com a consequente abertura de prazo processual para apresentação de RECURSO das partes.

Cumpra-se observar que o parágrafo único do art. 48 da LEP estabelece que a autoridade administrativa representará ao juiz da execução penal para adoção das sanções disciplinares previstas nos aludidos artigos.

Assim, RELEMBREMOS: antes desta representação, o diretor do presídio deve apurar a conduta do detento, identificá-la como falta leve, média ou grave, aplicar as medidas sancionatórias que lhe compete, no exercício de seu poder disciplinar, e, quando ficar constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, comunicar ao juiz da Vara de Execuções Penais para que decida a respeito das referidas sanções de sua competência, sem prejuízo daquelas já aplicadas pela autoridade administrativa.

• AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Por falta de previsão legal, não há um procedimento claro a ser cumprido, variando muito de acordo com cada estado, mas, em regra, têm-se uma audiência de justificação, circunstância na qual são analisadas as provas e ouvido o apenado, eventuais testemunhas, MP e defesa.

Reconhecida a falta grave judicialmente, o magistrado da execução irá imputar ao condenado uma série de restrições.

SANÇÕES JUDICIAIS

• REGRESSÃO DE REGIME

Por disposição do art. 118, I, LEP, reconhecida a prática de falta grave, ocorrerá a regressão para regime mais gravoso.

OBSERVAÇÃO: Uma das hipóteses de falta grave é a prática de crime doloso, internamente ou externamente ao estabelecimento prisional.

A Súmula 526, STJ, determina que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não exige o trânsito em julgado.

A jurisprudência não determina, porém, o que deve ser exigido, se bastaria um B.O. registrando o fato, o oferecimento da denúncia por parte do MP ou uma condenação em primeiro grau, por exemplo.

Na prática, o mero registro do fato em boletim de ocorrência já se faz suficiente para a instauração de um PAD e para o isolamento preventivo de 10 dias, cabível nas situações de falta grave, por determinação do art. 60, LEP.

• REGRESSÃO DE REGIME

Outra consequência é a perda de até 1/3 dos dias remidos, conforme disposição do art. 127, LEP.

Embora parte da doutrina considere que essa perda só seria possível se fosse por uma falta praticada durante o trabalho ou o estudo – justificando, dessa forma, a perda desses dias – a jurisprudência majoritária não admite essa tese.

TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: EP 8115431220228220000. Acórdão publicado em 09/03/2023

Ementa: Agravo em execução penal. Tentativa de fuga. Falta grave. Cometimento. Perda dos dias remidos. Fração de 1/6. Proporcionalidade. Razoabilidade. Caso concreto. Regressão de regime. Possibilidade. Recurso não provido. 1. Após ser reconhecida a prática de falta grave, impõe-se a aplicação das consequências previstas em lei. 2. Tendo o agravante tentado empreender fuga do estabelecimento prisional, está correta a decisão agravada que reconheceu a incidência da falta de natureza grave, posto que, nos termos da legislação, a tentativa é punida com a mesma sanção da falta consumada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos. 4. Agravo a que se nega provimento. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo nº 0811543-12.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 09/03/2023

TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: EP 8092800720228220000. Acórdão publicado em 08/03/2023

Ementa: Agravo de execução penal. Falta grave. Tentativa de fuga. Perda dos dias remidos. Redução. Impossibilidade. Agravo não provido. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a natureza, especialmente grave, da falta disciplinar – tentativa de fuga – constitui, de per si, fundamento apto para a decretação de perda de dias remidos, inclusive na fração máxima, nos termos do art. 57 da LEP. II - No caso, a decretação da perda de dias remidos em 1/3 foi devidamente fundamentada e, portanto, cumpre integralmente o requisito de motivação dos pronunciamentos judiciais dispostos no art. 93, IX, da Constituição da República e observa o princípio da proporcionalidade, ante a gravidade concreta da infração disciplinar cometida. III. Agravo que se nega provimento. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo nº 0809280-07.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 08/03/2023

• REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO

Revoga-se também a autorização para o trabalho externo, por determinação do parágrafo único do art. 37, LEP.

• REVOGAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA

O Sentenciado perde o direito para as saídas temporárias, de acordo com o art. 125, LEP.

• ALTERAÇÃO DA DATA BASE

Além da regressão de regime, ainda interrompe-se o prazo para futuras progressões, começando do zero, a partir da data da infração (e não da responsabilização, que pode levar meses), conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 534, STJ.

TJ-MG - Agravo em Execução Penal: AGEPN 10271170027699001 MG. Acórdão publicado em 26/08/2020

Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM REMIDO - NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO DOS DEMAIS BENEFÍCIOS PRISIONAIS PELO PRAZO DE DOZE MESES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA FALTA GRAVE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte -Depreende-se do artigo 185 da LEP que haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares -O reconhecimento de falta grave implica, dentre outras sanções, na regressão do regime carcerário, perda de dias remidos e na alteração da data-base para futuros benefícios -Punido em razão do cometimento de falta grave, deve o condenado ver sua pena-base alterada, fixando-se novo período para fins de cálculo de futuros benefícios, contado da data da última falta grave.

TJ-SC - Agravo de Execução Penal: EP 101063920158240038 Joinville 0010106-39.2015.8.24.0038. Acórdão publicado em 18/02/2016

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E DEIXOU DE ALTERAR A DATA-BASE PARA A CONTAGEM DE FUTUROS BENEFÍCIOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE QUE ENSEJA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONTAGEM DE FUTUROS BENEFÍCIOS. SÚMULA N. 534 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PROGRESSÃO DE REGIME. O reconhecimento da prática de falta grave acarreta a alteração da data-base para a contagem dos benefícios ulteriores, devendo esta recair sobre a data do cometimento do fato caracterizador da falta grave, tal como disposto na Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.

Porém, observe-se que, apesar de voltar a ser contado do zero, o preenchimento da fração necessária para a próxima progressão se dará em relação ao restante da pena, não mais em relação ao total.

- **Interrupção de lapso para benefícios (data-base)**

A lei exige sempre que o réu cumpra um determinado período (lapso) caso queira acessar seus benefícios, como, por exemplo, 1/6 da pena para progredir de regime (em casos de crime comum). A contagem começa normalmente na data em que o réu é preso (data-base).

Há uma discussão se o cometimento de falta grave interromperia (reiniciaria) o lapso temporal para obtenção de benefícios pelo réu, como a progressão de regime, o indulto e a comutação. A interrupção faria a contagem zerar e ser reiniciada no dia do cometimento da falta grave, devendo o réu cumprir o mesmo lapso, agora calculado sobre o tempo de pena restante – por exemplo, 1/6 da pena que ainda falta cumprir. Atualmente, temos três posicionamentos sobre tal tema:

- STJ: entende que o lapso se interrompe só para progressão de regime prisional. Para o livramento condicional, o indulto e a comutação não haveria interrupção (3ª Seção pacificou o assunto no RESP 1.176.486);
- STF: entende que se interrompe o lapso para progressão de regime (HC 109.389, Info 678/RHC 116.203, Info 705) e não dispõe sobre o livramento, o indulto e a comutação;
- Defensoria Pública: entende que não se interrompe o lapso para nada, por falta de expressa previsão legal. É posição minoritária.

• VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Por determinação da Súmula 441 do STJ, o reconhecimento da falta grave não impede, por si só, a vedação ao livramento condicional, nem gera alteração da data-base. A Súmula 535, STJ, também estabelece que não interrompe-se o prazo para indulto ou comutação.

Uma observação de suma importância é que embora o reconhecimento da falta grave não vede, por si só, o direito a alguns benefícios, acaba os vedando indiretamente, uma vez que, em regra, para ter direito à estes “estímulos”, o apenado precisa gozar de bom comportamento carcerário e não ter cometido falta grave nos últimos meses.

Assim, será necessário, no caso específico do Livramento Condicional, uma combativa Tese de Defesa argumentado que, passado 12 (meses) sem que o sentenciado tenha cometido Falta Disciplinar, encontra-se REABILITADO e, portanto, tem o direito garantido.

TJ-GO - Agravo de Execução Penal: AGV 2072838120208090000 GOIÂNIA. Acórdão publicado em 04/11/2020

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. O cometimento de falta grave não pode ser considerado impedimento para concessão do livramento condicional, se por esses mesmos fatos o reeducando já foi penalizado com a regressão de regime, sob pena de incorrer-se em bis in idem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1970217 MG 2021/0361139-0. Acórdão publicado em 01/06/2023 Precedente Obrigatório

Ementa: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea a do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido.

TESE DE DEFESA

Uma das Teses de Defesa quando do INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO condicional sob a alegação de FALTA GRAVE é a incidência da DUPLA PUNIÇÃO = bis in idem, uma vez que o sentenciado JÁ sofreu as sanções devidas advindas de sua falta grave e, portanto, estando REABILITADO não pode sofrer mais uma sanção com o INDEFERIMENTO do direito ao Livramento Condicional.

TJ-MG - Agravo em Execução Penal: AGEPN 10145160027911001 Juiz de Fora. Acórdão publicado em 22/06/2022

Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE DOZE MESES - RECURSO PROVIDO. A falta grave anterior ao período aquisitivo do livramento condicional não pode ser utilizada para indeferir o benefício ao agravante, que já suportou as consequências legais pela sua indisciplina, sob pena de se configurar um "bis in idem".

ATENÇÃO!

Ainda sobre o LIVRAMENTO CONDICIONAL, é preciso observar que o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS ao Livramento Condicional NÃO PODE SER APURADA COMO FALTA GRAVE!

Isto porque, a Lei já prevê SANÇÃO quando o sentenciado descumpri as condições do Livramento Condicional, que é, SUA REVOGAÇÃO.

PORTANTO, NÃO CONFUNDIR: DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO ENSEJA FALTA GRAVE e sim sanções previstas no próprio Instituto.

TJ-MG - Agravo em Execução Penal: AGEPN 10000210265211001 MG. Acórdão publicado em 23/06/2021

Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O PERÍODO DE PROVA - FALTA GRAVE RECONHECIDA E BENEFÍCIO REVOGADO - AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE E RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - NECESSIDADE. Não configura falta grave o descumprimento das condições impostas para o livramento condicional, pois o Código Penal e a Lei de Execução Penal já preveem a possibilidade de revogação do benefício. A despeito do descumprimento de uma das condições impostas quando da concessão do livramento condicional, mostra-se desproporcional e desarrazoada a revogação do benefício, pois, além de se tratar de revogação facultativa (artigo 87 do Código Penal), foram cumpridas todas as demais condições impostas para o livramento condicional.

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. Consoante o disposto nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal e forte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem consequências próprias previstas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, as quais não se confundem com os consectários legais da falta grave praticada por aquele que está inserto no sistema progressivo de cumprimento de pena". Determinada a cassação da decisão que reconheceu a falta grave no curso do período de prova do livramento condicional, tendo em vista a ausência de previsão legal. RECURSO PROVIDO.

• TRANSFERÊNCIA PARA O RDD – REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO

Sendo o caso de falta grave que ocasione subversão da ordem e da disciplina interna (como uma rebelião, por exemplo) ainda há possibilidade de transferência para Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), regulado pelo art. 52, LEP.

O caput do art. 52 dispõe que a prática de crime doloso também constitui falta grave. Além disso, este dispositivo prevê um regime disciplinar diferenciado para o preso que incorrer nessa hipótese de falta grave:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie;

II - recolhimento em cela individual;

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.

Outras situações que apresentam alta periculosidade são abrangidas pela decretação de regime disciplinar diferenciado, inclusive a liderança de organização criminosa, que importa em cumprimento de pena em estabelecimento federal:

Art. 52. [...]

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade;

II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.

§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal.

§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso:

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade;

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais.

§ 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário.

§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.

SANÇÕES DISCIPLINARES

Diante do cometimento de falta grave, a pessoa que praticou a falta poderá sofrer alguma das sanções disciplinares arroladas no artigo 53:

Art. 53. Constituem sanções disciplinares:

I - advertência verbal;

II - repreensão;

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado.

A regra geral é que a sanção será aplicada conforme a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato cometido pelo condenado, bem como se considerando a pessoa que cometeu a falta e seu tempo de prisão (art. 57, caput, da LEP).

Mas cuidado! No entanto, no caso das faltas graves, só poderão ser aplicadas as sanções previstas nos incisos de III a V (art. 57, parágrafo único, da LEP)!

E a falta grave caracterizada por cometimento de crime doloso é sempre punida com o regime disciplinar diferenciado (RDD) (art. 52, caput, da LEP).

Observe, portanto, que o RDD, apesar do nome, não é regime, é sanção disciplinar com as seguintes características:

Art. 52. (...)

I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada;

II - recolhimento em cela individual;

III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas;

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol.

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.

§ 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.

Atenção: os dois parágrafos do artigo acima descrevem duas hipóteses em que o RDD é aplicado independentemente da existência de uma falta disciplinar.

• **DECLASSIFICAÇÃO da FALTA GRAVE para FALTA MÉDIA ou LEVE**

Como vimos, o reconhecimento e homologação de uma FALTA GRAVE atinge diretamente os direitos do preso, dificultando-lhe sobremaneira a Progressão de Regime e, portanto, a conquista da tão esperada LIBERDADE.

Por isto, a advogada e o advogado deve buscar todos os meios de IMPEDIR que a FALTA GRAVE seja reconhecida e homologada, utilizando-se de conhecimento técnico e teses defensivas combativas e decisivas.

A DECLASSIFICAÇÃO da FALTA GRAVE para uma FALTA mais amena é uma dessas TESES, e você pode utilizar-se das seguintes argumentações, como: ausências de provas; falta de individualização da conduta; falta coletiva; falta de individualização da autoria certa e determinada; imputações genéricas, dentre outras.

- **AUSÊNCIA DE PROVAS**

Alegar **AUSÊNCIA** de provas contundentes para a CULPABILIZAÇÃO DO SEI CLIENTE.

TJ-SP - Agravo de Execução Penal: EP 70016781320188260482 Presidente Prudente. Acórdão publicado em 31/10/2023

Ementa: AGRADO DE EXECUÇÃO - Sindicância - Falta grave - Ameaça e subversão à ordem e à disciplina em tese ocorrida 25/10/2017. Pleiteia a defesa a desconstituição da falta grave atribuída ao agravante, diante da insuficiência probatória, corroborada pela negativa de autoria, além da ausência de prova individualizada da conduta, diante da vedação à sanção coletiva, a teor do artigo 45, § 3º, da LEP - Alternativamente, requer a desclassificação para falta de natureza média, em observância ao princípio da proporcionalidade - ADMISSIBILIDADE - Não há provas suficientes para afirmar que o agravante tenha concorrido para a prática de falta disciplinar grave - Invencível a dúvida, em respeito ao princípio in dubio pro reo, de rigor a absolvição. Subsidiariamente, requer a restituição dos dias remidos, limitando-se eventual perda ao mínimo legal, haja vista que o Juízo a quo não fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3 - PERDA DO OBJETO - Diante da absolvição do sindicado, restou prejudicado o pedido subsidiário. Agravo provido.

- FALTA GRAVE COLETIVA

Advinda, também, do princípio da necessária INDIVIDUALIZAÇÃO da conduta, o que leva, também, à tese da falta de individualização da própria AUTORIA.

STJ - HABEAS CORPUS: HC 365825 SP 2016/0206664-3. Acórdão publicado em 27/03/2017

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO. SANÇÃO COLETIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal, diante de depredação de bem público quando, havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado" (HC-292.869/SP . Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA TURMA, Dje 29/10/2014) 3. In casu, o agredido identificou os colegas detentos que teriam participado da agressão, mas não há nada nos documentos encaminhados para apuração da falta grave que descreva a conduta individualizada do paciente. 4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular o reconhecimento de falta grave e seus consectários legais.

-AUTORIA NÃO DETERMINADA

TJ-SP - Agravo de Execução Penal: EP 99977620208260496 SP 0009997-76.2020.8.26.0496. Acórdão publicado em 31/03/2021

Ementa: Agravo em execução - Falta grave – Sentenciada que teria agredido outra detenta – Alegação desta de ter agido em legítima defesa – Provas produzidas insuficientes a dirimir dúvidas quanto a quem teria dado início à contenda, restando isoladas as versões da agravante e da suposta vítima - Recurso provido para absolver a agravante.

TJ-MG - Agravo em Execução Penal: AGEPN 1000022283384001 MG. Acórdão publicado em 01/03/2023

Ementa: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - NOVO CRIME - PROVAS DA AUTORIA - INEXISTÊNCIA - DENÚNCIA NÃO OFERECIDA - 1. Inexistindo elementos judiciais que comprovem a autoria do suposto ato de indisciplina, torna-se inviável o seu reconhecimento da prática de falta grave. 2. Se não foi oferecida denúncia contra o reeducando em razão da ausência de provas acerca da autoria do suposto novo delito, não há se falar em reconhecimento da falta grave.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 740321 SP 2022/0133556-8. Acórdão publicado em 14/06/2022

Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPUTADA AO REEDUCANDO POR ATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE TERIA CONCORRIDO PARA A CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que, em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada sua autoria, através de elementos concretos. 2. In casu, não ficou provada a prática de ato material pelo paciente. O fato de ser sua genitora a remetente do SEDEX e a simples suspeita de que ele teria sido o solicitante do entorpecente não são suficientes para afirmar a prática da falta grave, especialmente ao se considerar que o reeducando sequer teve consigo a posse do material que lhe havia sido enviado. 3. Agravo regimental desprovido.

-IMPUTAÇÃO GENÉRICA

TJ-SP - Agravo de Execução Penal: EP 60788720218260482 SP 0006078-87.2021.8.26.0482. Acórdão publicado em 27/05/2021

Ementa: FALTA GRAVE – Artigo 50 , I e VI da LEP – Liderança negativa e apologia ao crime organizado - Inviabilidade de reconhecimento da falta disciplinar – Elementos insuficientes para sua caracterização: comunicação de evento genérica, negativa do agravante e declaração dos funcionários insuficientes para atribuir ao sentenciado conduta negativa específica – Absolvção que se impõe - Recurso provido (voto 44490).

PRESCRIÇÃO – FALTA GRAVE

Antes de mais nada, é preciso esclarecer que existe diferença entre a PRESCRIÇÃO, ou melhor, o PRAZO para APURAÇÃO ADMINISTRATIVA da FALTA GRAVE e a PRESCRIÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE, que é o PRAZO para HOMOLOGAÇÃO da FALTA GRAVE e, portanto a APLICAÇÃO das SANÇÕES JURÍDICAS.

A verdade é que NEM UM DOS PRAZOS está expressamente previsto em Lei, valendo, portanto, os PRAZOS estabelecidos pelas NORMAS de cada estado.

No caso do PRAZO para a APURAÇÃO ADMINISTRATIVA da FALTA DISCIPLINAR, por meio do PAD variam de acordo com os REGIMENTOS PENITENCIÁRIOS de cada estado, variando de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias.

Assim, não cumpridos o PRAZO estabelecido pelo REGIMENTO para a CONCLUSÃO do PAD, não podem ser APLICADAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, declarando-se a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA em sede ADMINISTRATIVA da FALTA GRAVE ao sentenciado.

ENTRETANTO, a PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO AFETA a possibilidade da HOMOLOGAÇÃO e consequente APLICAÇÃO DE SANÇÕES JUDICIAIS pela prática de FALTA GRAVE. Tratando-se, de PRESCRIÇÕES INDEPENDENTES.

Assim, em relação à PRESCRIÇÃO JUDICIAL, tem-se pacificado em nossos Tribunais que o PRAZO é de 03 (três) ANOS.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 1702078 SP 2017/0254274-2. Acórdão publicado em 25/09/2018

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. NÃO DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos do disposto na Lei n. 12.234 /2010. 2. Não há falar em prescrição, porquanto não transcorrido o prazo prescricional de 3 anos entre a ocorrência da falta grave e a data da homologação pelo juízo das execuções. 3. Agravo regimental provido para, afastada a extinção da punibilidade pela prescrição, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do agravo em execução interposto pela defesa.

Considerando que, como dito acima, não há uma PREVISÃO LEGAL, de forma expressa quanto o Prazo prescricional, deve-se considerar o MENOR LAPSO TEMPORAL previsto no Código Penal, que se encontra no Art. 109.

TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: EP 8088972920228220000. Acórdão publicado em 27/10/2022

Ementa: Execução penal. Cometimento de novo crime no curso da execução. Falta grave. Prescrição. Ocorrência. Agravo provido. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão para se apurar falta disciplinar cometida no curso da execução penal deve ser regulada, por analogia, pelo menor prazo do art. 109 do Código Penal, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. 2. O Estado perde o direito de apurar a falta grave quando transcorrido o lapso temporal máximo para esse desiderato, fulminado que foi pela ocorrência da prescrição. 3. Agravo provido. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo nº 0808897-29.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 27/10/2022

TJ-MG - Agravo em Execução Penal: AGEPN 10231160130226002 Ribeirão das Neves. Acórdão publicado em 15/02/2022

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE -PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE PRAZO DE TRÊS ANOS - ARTIGO 109 INCISO VI DO CÓDIGO PENAL - RECURSO IMPROVIDO. Apesar de o artigo 83 do Código Penal ter sido alterado pela Lei Anticrime, incluindo que o "não cometimento de falta grave nos últimos 12 doze meses" como requisito para a concessão do livramento condicional, prevalece o entendimento segundo o qual a prescrição da falta grave se verifica em 03 três anos, aplicando-se o menor prazo estabelecido no Código Penal.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 724598 GO 2022/0047012-6. Acórdão publicado em 29/04/2022

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três anos (inciso VI)). Precedentes. 2. Na espécie, a prática da falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 01/06/2019, e a decisão homologatória do seu reconhecimento se deu em 26/04/2021 (fls. 68-73). Portanto, não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional. 3. O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, como se sabe, dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

Atenção especial à DATA do COMETIMENTO DA FALTA GRAVE, nos casos de FUGA.

Deve-se lembrar que a FALTA GRAVE consistente na FUGA é um crime que se perpetua no tempo, ou seja, PERMANENTE isto é, ela continua acontecendo até que o Sentenciado seja recapturado.

Portanto, a DATA do INICÍO da contagem da PRESCRIÇÃO, será a DATA DA RECAPTURA.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 779723 SP 2022/0338650-2. Acórdão publicado em 30/03/2023

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. FUGA. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o agravante deixou de comparecer em juízo no dia 5/12/2014, tendo sido recapturado em flagrante na data de 17/10/2015.2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente.3. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três anos).4. Não decorreu lapso superior ao mencionado entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17/10/2015, e a data de sua homologação judicial, em 19/7/2018. 5. Agravo regimental desprovido.

E não faria outro sentido. Se não, isto incentivaria que o sentenciado permanecessem foragidos até prescrever a possibilidade de lhe ser aplicada as SANÇÕES relativas ao cometimento da falta, ao invés de incentivá-lo a reapresentar-se, entregar-se e voltar a cumprir sua reprimenda, a fim de cumprir os fins a que a PENA se destina – sua reinserção social.

OBSERVAÇÃO 1.: Com referência a possibilidade de fixação da PRESCRIÇÃO JUDICIAL DE FALTA GRAVE, pelos REGULAMENTOS próprios de cada estado, a Jurisprudência entende ser INCONSTITUCIONAL, considerando-se que a competência para LEGISLAR sobre DIREITO PENAL é exclusiva da União – Art. 24, I, CF.

OBSERVAÇÃO 2.: na mesma linha de raciocínio de ser necessário considerar-se o MENOR PRAZO previsto no Código Penal para a aplicação do PRAZOM PRESCRICINAL, a DEFESA deve fazer valer a aplicabilidade da REDUÇÃO DESTES PRAZO para aqueles sentenciados que, quando do cometimento da FALTA GRAVE eram menores de 21 (vinte e um) anos ou maiores de 70 (setenta) anos, fundamentando no Art. 115, CP.

REABILITAÇÃO DA FALTA GRAVE

Em verdade, até a promulgação do PACOTE ANTI-CRIME, não havia uma PREVISÃO LEGAL ditando qual era o PRAZO para que o Sentenciado fosse considerado REABILITADO de uma FALTA GRAVE.

Está questão era tratada de forma isolada, pelos Regulamentos Penitenciários de cada estado, gerando, assim, diferenciação de cada local com referência a esta questão.

Agora, com a alteração legislativa, nos temos expresse no Art. 112, § 7º, o PRAZO DE 01 ANO para que o Sentenciado possa, novamente, ser ATESTADO com BOA CONDUTA CARCERÁRIA.

LEP. Art. 112. § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito

A CONTAGEM DO PRAZO para a REABILITAÇÃO, se inicia na DATA DO FATO que gerou a FALTA GRAVE, e não do encerramento da apuração ou imposição das sanções disciplinares ou, ainda, da homologação judicial.

A REABILITAÇÃO deverá ser requerida ao JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, mediante a COMPROVAÇÃO de BOM COMPORTAMENTO, que dependerá, obviamente, da manifestação do Diretor da Unidade Prisional, através da emissão de ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA.

OBSERVAÇÃO. Não existe uma previsão legal EXGINDO a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para a concessão da REABILITAÇÃO. Entretanto, também não se nega esta possibilidade de exigência, pelo Juízo da execução penal, quando, assim, de forma MOTIVADA, ele entender necessário.

É de extrema importância que o Advogado e Advogada atuante na execução penal, requeira a REABILITAÇÃO do cliente. Isto porque, após DEFERIDA a REABILITAÇÃO pelo Juízo da Execução, a FALTA REABILITADA não poderá ensejar óbices à obtenção de benefícios, dando celeridade aos trabalhos jurídicos que se seguirem na Execução Penal do cliente.

Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO ANTES DA FLUÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ÚLTIMA FALTA GRAVE COMETIDA – REABILITAÇÃO DA CONDUTA – ART. 112, § 7º, DA LEP – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. I – Se houve o cumprimento do lapso temporal exigível para a progressão prisional, o bom comportamento poderá ser readquirido em prazo inferior a 12 meses da ocorrência da última falta grave, conforme expressamente dispõe o art. 112, § 7º, da LEP. No caso dos autos, a agravante atendeu ao requisito objetivo antes da fluência dos 12 meses contados a partir da última falta grave, bem como não registra atos de indisciplina durante a permanência no atual regime. Assim, atendidos os requisitos legais, impõe-se a concessão da progressão prisional. II – Recurso provido.

E É, TAMBÉM POR ISSO, QUE É MUITO IMPORTANTE, observar que existe a possibilidade de REDUÇÃO DESTE PRAZO de 01 ANO para o pedido de REABILITAÇÃO!

Esta possibilidade ocorre quando o Sentenciado ATINGE LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME.

Leia novamente o § 7º acima:

O bom comportamento é readquirido (= REABILITAÇÃO DA FALTA GRAVE)

após 1 (um) ano da ocorrência do fato
ou antes

após o cumprimento do requisito temporal exigível (ou seja, CUMPRIDO O LAPSO TEMPORAL)

para a obtenção do direito = DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME – prevista no caput do Art. 112:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso (...)

ATENÇÃO para os casos de FALTA GRAVE decorrente de FUGA: Neste caso, o prazo para reabilitação se inicia com a RECAPTURA.

**TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade 16026487120238120000
Campo Grande. Acórdão publicado em 17/10/2023**

Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO PREENCHEU O REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – PERÍODO DE REABILITAÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO IMPROVIDO. Para a falta grave consistente na fuga, o período de reabilitação de um ano para o preenchimento do requisito subjetivo da progressão regime prisional, deverá ter início da recaptura do reeducando. Se entre a data da recaptura e o pedido de progressão tiver decorrido um ano, não há falar na presença do requisito subjetivo para a progressão do regime prisional. Recurso improvido.

CONCLUSÃO FINAL

Temos assim, que não se trata de um tema complexo, entretanto é de extrema importância para a LIBERDADE do Cliente e exige uma combativa e RÁPIDA intervenção de defesa técnica.

Evitar que o Cliente seja condenado em uma falta é crucial e, para isso, é preciso dominar a técnica de atuação no PAD.

Por fim, deve ser lembrado que, assim que iniciado um PAD para apuração de Falta Grave, muito possivelmente o Sentenciado será “regredido” cautelarmente de Regime, até apuração final.

TJ-SP - Agravo de Execução Penal: EP 41014220228260509 SP 0004101-42.2022.8.26.0509. Acórdão publicado em 10/10/2022

Ementa: Agravo em execução. Falta grave. Insurgência do sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido para que fosse mantido no regime semiaberto enquanto pendente de conclusão a sindicância de falta grave. O regime semiaberto fora susgado cautelarmente em razão da sindicância disciplinar instaurada em face do sentenciado. A susgação do regime é providência cautelar exequível pelo juízo. Poder de cautela do juízo. Precedentes. Excesso de prazo para conclusão do procedimento administrativo de apuração de falta disciplinar. Prazo superior ao previsto em regulamento que se justifica pela complexidade dos fatos e quantidade de investigados. O prazo previsto no artigo 62 da Resolução nº 144/2010 da SAP não tem caráter peremptório e, caso constatado o transcurso do prazo in albis, é mera irregularidade. Precedentes. Decisão mantida. Agravo não provido.

Ainda assim, a DEFESA TÉCNICA tem que estar atenta para as peculiaridades de cada caso e evitar, até mesmo a regressão cautelar de seu Cliente, para o Regime mais gravoso.

TJ-RS - Habeas Corpus Criminal: HC 70084102276 RS. Acórdão publicado em 04/06/2020

Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. Paciente que cumpre pena por duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. Juízo da Vara de Execuções Criminais que determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, pelo suposto cometimento de falta grave em razão de possível prática de novo delito no curso da execução penal. Ausência de motivação idônea para a regressão cautelar durante o trâmite do Procedimento Administrativo Disciplinar. Paciente que, em 08 de janeiro de 2020, teria sido preso em flagrante no processo de nº 001/2.20.0000589-1, pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Auto de Prisão em Flagrante que não foi homologado, e a liberdade foi concedida ao paciente, tendo em vista o reconhecimento de violação domiciliar. Magistrado que, na origem, sinalizou a possibilidade de absolvição por ausência de materialidade, diante do reconhecimento de violação domiciliar. Ainda que instaurado o PAD, em caso de eventual absolvição no processo de nº 001/2.20.0000589-1, não se poderia reconhecer a falta grave e aplicar os consectários legais. Determinação de que o paciente volte a cumprir pena no regime semiaberto. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

Bom Trabalho!!

E lembrem-se sempre: CADA DIA DE LIBERDADE IMPORTA e nós, Advogados e Advogadas devemos Lutar por eles!